

1500335-65.2022.8.26.0618
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: João Carlos Germano
Comarca: Taubaté
Foro: Foro de Taubaté
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/06/2022
... vive.

No caso concreto o réu tem diversas passagens por ato análogo ao tráfico na Vara da Infância e da Juventude, a evidenciar seu profundo envolvimento com o tráfico desde a menoridade, remontando sua interação com o tráfico desde 2016, assim como pela quantidade de droga com ele apreendida.

Tais registros são suficientes à demonstração de que o réu não é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Taubaté
Foro de Taubaté
3ª Vara Criminal
Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal
CEP: 12020-070 - Taubaté - SP
Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500335-65.2022.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500335-65.2022.8.26.0618
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Gustavo Cristiano Ferreira

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Gustavo Cristiano Ferreira foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 12 de março de 2022, por volta das 17h30min, na Avenida Francisco Barreto Leme, nº 778, Bairro Areão, nesta cidade e comarca de Taubaté, para fins de tráfico, transportava na motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, placa DLJ 7181, drogas, que causam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Paraná, nº 32, Vila São Geraldo, nesta cidade e comarca de Taubaté, Gustavo Cristiano Ferreira, guardava e tinha em depósito, drogas, que causam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Gustavo Cristiano

Ferreira, possuía, no interior de sua residência, 27 munições calibre 22 íntegras, e 7 munições íntegras e 1 deflagrada, calibre 32, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado pela acusação, o réu decidiu dedicar-se ao nefasto crime de tráfico de drogas. Para tanto, transportava drogas no veículo, bem como armazenava entorpecentes e munições na residência.

Afirma o Ministério Público que, em patrulhamento de rotina, policiais visualizaram-no trafegando com a moto descrita na via pública e decidiram pela abordagem. Revistado, foram localizadas 2 porções de Cannabis Sativa L e R\$ 9,00 em espécie.

Indagado, o réu confessou que utilizava o veículo para o transporte das drogas e as armazenava em sua residência. Em razão disso, os agentes se dirigiram ao endereço dele, onde foram atendidos pela genitora, que autorizou a entrada.

Em vistoria, localizaram no quarto do réu 1 tijolo de Cannabis Sativa L; 1 recipiente com a referida droga; 1 telefone celular; R\$ 145,00 em espécie; 1 balança de precisão; 27 munições, calibre 22; 7 munições, calibre 32; e 1 projétil deflagrado, calibre 32.

Na oportunidade, o réu afirmou que vendeu um revólver calibre 32.

As drogas apreendidas possuem peso líquido de 466,6 gramas.

A finalidade de tráfico é percebida pela quantidade de drogas apreendidas, pelo modo de embalagem, o valor em dinheiro, as circunstâncias do crime, entre outras circunstâncias da prisão.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida às fls. 84/87.

Citado pessoalmente (fls. 123), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 96/111.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do réu, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Ouvidos em juízo, os policiais confirmaram os fatos e todas as circunstâncias, narrando a apreensão dos entorpecentes e demais objetos, explicando que iniciaram a abordagem do réu por investigação de outro crime. Na ocasião, ele confessou que fazia o tráfico de drogas e indicou que possuía mais entorpecentes em sua residência. Em juízo, o réu escolheu permanecer em silêncio, sendo entrevistado pelos advogados de Defesa. Nesse sentido, anotou que os policiais apresentaram depoimento coeso, seguro e uniforme, e nada há de concreto a tornar suspeitas suas versões, uma vez que sequer conheciam o réu. Conforme se apurou, os policiais ingressaram na residência por justa causa e com autorização da proprietária. Ressaltou que o réu é menor de 21 anos e possui passagens por tráfico de drogas na Vara da Infância e Juventude. Ademais, em seu interrogatório, ele não esclareceu as circunstâncias de sua abordagem e localização das drogas, salientando que ele teria confessado aos policiais que trabalhava com delivery de entorpecentes, utilizando-se de sua motocicleta. Por todos esses fatos, defendeu que a quantidade apreendida

é incompatível com mero usuário, inclusive, por estar em conjunto com munições e uma balança de precisão. Nesse cenário, requereu sua condenação nos exatos termos da denúncia. Na dosimetria, pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a quantidade de drogas localizadas. Na segunda fase, vislumbrou a atenuante da menoridade relativa. No caso concreto, entendeu não ser possível a aplicação do redutor, tendo em vista que este é destinado a pequeno e eventual traficante. Com relações às munições, apontou que o laudo demonstrou a potencialidade lesiva. Para cumprimento de pena, solicitou que seja fixado o regime fechado, em razão da gravidade do crime, equiparado aos crimes hediondos. Por fim, pediu o perdimento do numerário e da motocicleta em favor da União.

A Defesa, por sua vez, preliminarmente, solicitou a anulação do feito, com base nos depoimentos conflitantes das testemunhas. Salientou que a abordagem foi realizada sem justa causa, uma vez que os policiais não souberam delimitar qual seria a atitude suspeita, mencionando as características do réu e sua motocicleta. Ressaltou, ainda, a verificação de outro fundamento de anulação, diante da ausência de aviso do direito ao silêncio por ocasião da abordagem. Afirmou que houve prejuízo constatado materialmente, perante a autoincriminação do réu. Ademais, na revista do imóvel, afirmou que não foram seguidos os procedimentos previstos em lei. Inclusive, ambas as testemunhas foram incoerentes nesse quesito, considerando que não souberam delimitar como foi feito o primeiro contato com a proprietária da residência. Por essas circunstâncias, pleiteou a anulação e desvinculação de todas as provas obtidas por meios ilícitos. Solicitou, ainda, a absolvição do réu. Caso o entendimento não seja este, defendeu que o réu era usuário de drogas, enquadrando-se no artigo 28, o que ensejaria a desclassificação, em eventual condenação. Por fim, pediu a liberdade provisória.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

As questões preliminares suscitadas confundem-se com o mérito e, como ele serão analisadas. As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 3/5), termo de depoimento (fls. 6/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), auto de qualificação, vida pregressa e BIC (fls. 22), laudo pericial (fls. 125/128 e 238/240) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas e posse de munição.

A testemunha Oesley Eduardo da Silva Pereira, ouvida em juízo, narrou que, no dia dos fatos, estavam apurando um crime de homicídio, acontecido em data anterior, no qual as características do autor eram semelhantes às do réu. Ao avistar a viatura, o réu demonstrou nervosismo. Durante a abordagem, assim que retirou o capacete, verificaram que ele não era o autor. Apesar disso, diante da atitude suspeita, procederam a revista pessoal, localizando 2 porções de maconha e dinheiro. No momento, quando foi indagado, o réu confessou que fazia delivery dos entorpecentes. Além disso, ele relatou que morava a 2 quarteirões, onde teria mais drogas. No endereço indicado, fizeram contato com a genitora e a avó do réu, que autorizaram a

entrada e permaneceram na entrada na casa, acompanhando a revista. No quarto do réu, foi localizado 1 tijolo de maconha; 1 recipiente com a referida droga; 1 telefone celular; R\$ 145,00 em espécie; 1 balança de precisão; 27 munições, calibre 22; 7 munições, calibre 32; e 1 projétil deflagrado, calibre 32. Na ocasião, ele informou que não possuía o armamento e estava vendendo as munições aos poucos. A respeito das drogas, ele confessou que as cortava e fazia a revenda. Afirmou que não o conhecia anteriormente. Garantiu que ele colaborou com a equipe policial a todo momento. Não se recorda das características do indivíduo procurado ou se informou ao réu sobre seu direito de permanecer em silêncio. Mencionou que tentaram acessar o celular, na residência, sem sucesso. Perguntado, disse não se recordar quanto tempo durou a diligência na casa. Negou que a proprietária tenha assinado qualquer termo.

A testemunha Fábio Nogueira Silva, ouvida em juízo, narrou que, na madrugada do dia dos fatos, havia acontecido um crime de homicídio, no qual o autor teria se evadido em uma motocicleta idêntica à do réu. Nesse cenário, ao avistá-lo na via, optaram por sua abordagem. Durante a busca pessoal, encontraram 2 porções de maconha e dinheiro. Mencionou que fizeram a verificação sistêmica do veículo, e este estava regular. Na ocasião, o réu confessou que vendia drogas por delivery. Além disso, ele mencionou que teria mais entorpecentes em sua residência. No endereço, foram recebidos pela genitora e a avó do réu, que imediatamente autorizaram a entrada. No quarto dele, localizaram 1 tijolo de maconha; 1 recipiente com a referida droga; 1 telefone celular; dinheiro em espécie; 1 balança de precisão; 27 munições, calibre 22; 7 munições, calibre 32; e 1 projétil deflagrado, calibre 32. No momento, ele alegou que teria vendido o armamento para um indivíduo não identificado, em data anterior, e teria mantido as munições. Questionado, disse que a mãe do réu foi qualificada na Delegacia e acompanhou a elaboração do boletim de ocorrência. Perguntado, disse que não informaram diretamente ao réu sobre seu direito de permanecer em silêncio, devido à informalidade da conversa. Negou que tivesse maiores informações sobre o suspeito de homicídio. Citou que seu parceiro fez o primeiro contato com a proprietária da casa. Não soube dizer quanto tempo permaneceram no local, acreditando que tenham ficado no máximo 40 minutos. Sobre o celular, recorda-se que ele foi levado à Delegacia para averiguação.

Daniela, ouvida em juízo, informou que é mãe do réu. Narrou que os policiais invadiram sua residência, sem sua autorização. Além disso, negou que tenha acompanhado a revista no local. Indagada, disse que seu depoimento foi dispensado na Delegacia. Mencionou que um dos policiais pediu que ela assinasse algo na tela de seu celular. Afirmou que forneceu seu documento à equipe, recuperando-o posteriormente. Relatou que, na oportunidade, estava em sua casa, quando ouviu uma gritaria, e logo em seguida os policiais apareceram em sua sala. Diante das circunstâncias, permitiu que eles fizessem a revista. Citou que foi à Delegacia cerca de 1 hora depois, por vontade própria. Questionada, disse que o material apreendido era de propriedade do réu, e que ele é usuário de maconha há algum tempo e que já fez uso de cocaína. Negou conhecimento da quantidade maior. Destacou que ele foi detido anteriormente por posse de drogas, quando menor de idade.

O réu Gustavo Cristiano Ferreira, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e escolheu responder apenas às perguntas da Defesa. Afirmou que é usuário de maconha e fez tratamento para o vício. Informou que ganhou a motocicleta de sua tia e o celular de sua mãe, para trabalhar de motoboy. Citou que, durante a abordagem, não foi notificado que poderia permanecer em silêncio.

Bem provadas a autoria e a materialidade relativamente ao delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, e artigo 12, da Lei 10.826/03, que rezam:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

" Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa."

Do arcabouço probatório, não se tem dúvida de que os fatos atinentes ao tráfico e à posse de munição se passaram na forma como narrada na denúncia, rendendo ensejo à necessária certeza que ora embasa o édito condenatório.

Como se infere da instrução, os policiais que realizaram a prisão do réu, em relato coeso e uniforme, disseram que o abordaram e com ele encontraram droga. Ao depois, em revista na casa dele, encontraram mais entorpecente e munições.

Registro que os depoimentos prestados são coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos.

Some-se a isso a grande quantidade de droga apreendida, petrechos e as munições.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalta-se que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Não se tem, assim, dúvida acerca da responsabilidade do réu.

Quanto às teses defensivas, nenhuma delas é capaz de afastar a responsabilidade do réu.

A alegação de falta de justa causa para a abordagem não se configurou e, mesmo que não existisse justa causa para que o réu fosse abordado, ainda assim não haveria nulidade.

Verifica-se que dos policiais ouvidos, Oesley não tinha muitas recordações do fato, mas se lembrou que foram atendidos pela mãe e pela avó do réu, que franquearam a entrada deles no imóvel.

Além disso, é extremamente natural que os policiais não se recordem exatamente dos fatos como passados, dado que as apreensões e combate ao crime é o que vivenciam

diariamente por conta do trabalho deles, sendo compreensível distorções mínimas em suas falas.

A alegação de que não resultou devidamente esclarecido o que motivou a abordagem do réu não se coaduna com as provas nos autos existentes. Os policiais afirmaram que buscavam por um suspeito de um crime com as características do réu, notadamente a motocicleta.

Ademais, o motivo pelo qual suspeitaram do réu mostra-se irrelevante, sendo certo que, a partir de suspeita e abordagem, com ele encontraram drogas que constitui crime permanente e autorizava o flagrante, não havendo, aí, qualquer nulidade.

No que se relaciona à alegação de que ao réu não foi dado o Aviso de Miranda, equivocada está a Defesa.

Com efeito, o que se procede em um primeiro momento é uma entrevista que os policiais fazem com o réu, até mesmo para entender a situação e aferir se realmente lhes parece ser caso de flagrante ou não.

Dali, concluindo que há crime, levarão o réu à Delegacia onde, aí sim, será ele assegurado de seus direitos – inclusive o de permanecer calado – como efetivamente se deu com o réu neste feito, quando, na delegacia, optou pelo silêncio.

Não houve, então, qualquer malversação ao denominado Aviso de Miranda, certo de que ao réu foi garantido o direito de permanecer em silêncio e assim o fez.

Sob outro aspecto, calha dizer que eventual irregularidade na advertência em questão, configura irregularidade relativa, cabendo ao réu demonstrar o prejuízo a que foi submetido (AgRg no AREsp 1922091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No caso concreto, não há alegação de qualquer prejuízo, sendo a nulidade invocada por si só, o que demanda o seu não acolhimento.

A afirmação de que a entrada dos policiais na casa do réu não atendeu às determinações legais, com a devida vênia, não se sustenta.

Com efeito, um dos policiais ouvidos e que bem se lembrava dos fatos afirmou que a mãe e a avó do réu franquearam a eles a busca em seu domicílio.

A alegação da mãe do réu – porque não isenta – não se sobrepõe à palavra dos policiais, que são funcionários públicos, dotados de fé pública, não havendo nenhum indício de que não tenham trazido a verdade à tona.

Nada obstante, o ingresso na residência foi precedido do encontro de drogas em poder do réu em busca pessoal realizada na via pública, e, nas circunstâncias, havia fundado motivo para que os policiais acreditassem que havia mais drogas na residência do réu.

Além do mais, foi postulada a vinda das imagens das câmeras corporais dos policiais, contudo, ao findar-se a instrução, deixou a Defesa de requerer a diligência faltante, renunciando à prova antes postulada, com o encerramento da fase instrutória.

Nada obstante, como é cediço, o crime de tráfico de drogas constitui crime permanente, de forma que enquanto a pessoa possuir entorpecentes para esse fim (tráfico ilícito) pode ser presa em flagrante, podendo, inclusive, ocorrer a violabilidade do domicílio, haja vista configurar uma das hipóteses constitucionalmente previstas, qual seja, a ocorrência de flagrante delito dentro

da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Tal entendimento é consagrado na doutrina e na jurisprudência e foi novamente referendado em decisão recente, proferida há poucos dias, do Supremo Tribunal Federal.

"A posse de droga para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado (RHC 213852 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 30 de maio de 2022, processo eletrônico DJe-106, divulgado em 31.5.2002, publicado em 1.6.2022).

Diante de tal quadro, se afigura evidente que a prova amealhada nos autos foi obtida de forma lícita e regular, não se verificando nenhuma nulidade.

Quanto à alegação de que é o réu apenas usuário, a quantidade de drogas apreendidas demonstra o contrário.

Com efeito, foram com o réu encontrados quase 500g de maconha, quantidade essa que obviamente demonstra que não se trata de um mero usuário. Some-se a isso a balança de precisão encontrada, que comprova o fato de que dividia a droga em pedaços para venda no varejo.

Além disso, tinha o réu droga que levava com ele, certamente objeto de venda, que seria entregue a alguém, contudo, foi pela polícia interceptado.

Não há dúvida, assim, da destinação ao tráfico.

Há de se reconhecer a atenuante da menoridade relativa do réu, o que será valorado no momento oportuno.

Como bem pontuado pelo Ministério Público não se verifica, no caso, a hipótese prevista no artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/06.

De se anotar que a redução prevista na lei busca alcançar e tem por finalidade aquele pequeno traficante. É a ele que a lei visa a conceder a benesse, promovendo-lhe uma nova chance para que se ajuste ao meio social em que vive.

No caso concreto o réu tem diversas passagens por ato análogo ao tráfico na Vara da Infância e da Juventude, a evidenciar seu profundo envolvimento com o tráfico desde a menoridade, remontando sua interação com o tráfico desde 2016, assim como pela quantidade de droga com ele apreendida.

Tais registros são suficientes à demonstração de que o réu não é um pequeno traficante, mas que tem como meio de vida a traficância, o que é hábil a afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4.º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido a jurisprudência.

"(...) 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou Maus Antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido." (STJ AgRg no REsp nº 1560667/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 17.10.2017, DJe 23.10.2017. No mesmo sentido: STJ AgRg no

REsp 1653501/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 09.05.2017, DJe 17.05.2017; e STJ HC nº 299.673/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.08.2016, DJe 24.08.2016.

Na data dos fatos o réu era imputável. Tinha plena consciência da ilicitude praticada e, ainda assim, persistiu no intento deletério.

A prova é certa, segura e dá conta do ilícito praticado pelo réu, que devem responder penalmente pelos delitos que lhes são imputados.

Passa-se, agora, à dosimetria da pena com fundamento no artigo 68, do Código Penal, observando-se o critério trifásico desenvolvido por Nelson Hungria e atento ao princípio da individualização da pena.

Do tráfico

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social da agente.

Verifica-se que a quantidade de drogas é relevante e pesa em desfavor do réu, tratando-se de quase 500g de maconha.

No que se refere à personalidade do agente, nada há a ser valorado, ante a falta de elementos.

No que respeita à culpabilidade, o que se vê é natural à espécie.

O réu é primário.

Acerca da conduta social do réu não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Considerando-se a quantidade de droga, eleva-se a pena em 1/6, alçando-a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a menoridade relativa, que faz tornar a pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da reprimenda, observo a inexistência de causa de diminuição ou mesmo de aumento, fixada assim definitivamente em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Da posse de munição

Na primeira fase de aplicação da pena, relativamente às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, vê-se que a culpabilidade do réu é natural à espécie, nada havendo a se valorar.

O réu é primário e, acerca de sua conduta social, não há elementos para valoração.

Quanto à personalidade nada há a ser valorado.

Os motivos do crime são os naturais à espécie, bem como as consequências são

ordinárias, sendo, assim, neutras para o fim de fixação da pena.

A vítima, no caso, é a coletividade, que não teve influência na prática do delito.

Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena no mínimo legal de 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a atenuante da menoridade relativa que, contudo, não pode levar a pena aquém do mínimo, em razão da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, não havendo circunstância agravante, fixada em 1 ano de detenção e 10 dias multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento, fixando-se, definitivamente, a pena em 1 ano de detenção e 10 dias multa.

Do cúmulo material

Tendo em conta que os delitos foram cometidos mediante mais de uma ação, impõe-se o reconhecimento do concurso material de crimes, que importa somar as penas, de acordo com o artigo 69, do Código Penal, cabendo observar que ao crime do delito do artigo 12, da Lei 10.826/03, a pena cominada é de detenção.

Assim, diante das naturezas distintas das penas, de rigor a aplicação cumulativa das reprimendas de reclusão e de detenção, devendo aquela ser executada primeiramente, nos termos do artigo 69, parte final, do Código Penal.

O regime inicial será o fechado para o delito de tráfico e aberto para a posse de munição.

O delito de tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que denotam conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta também exige maior rigor por parte do Estado.

Justifica-se o regime mais gravoso também pela significativa quantidade de entorpecentes.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "A quantidade de droga apreendida revela a gravidade concreta do delito, justificando a imposição do regime inicial fechado na hipótese dos autos". (STJ, HC nº 315.829/MG, rel. Ministro Ericson Marinho, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015, DJE 05/06/2015).

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena em razão, primeiro, da quantidade da apenação. De outro modo, a medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do direito. Ademais, levando-se em conta, mais uma vez, a gravidade in concreto do crime, insuficiente seria sua aplicação, com fundamento no artigo 44, inciso III, do Código Penal. Sendo incabível a substituição pelo tráfico, fica inviabilizada a substituição pela posse de munição.

Incabível, outrossim, a suspensão da pena prevista no artigo 77, em razão da reprovabilidade e da perniciosidade das condutas. Com relação ao tráfico, tanto pela pena, como por afrontar o espírito da Lei 11.343/06, que em seu artigo 44, veda a concessão de sursis.

Anote-se, ainda, que a despeito da Resolução n 5, do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no §4.º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a conversão e o sursis não se fazem adequados à prevenção e repressão do crime em espécie, pois, como já se decidiu, "os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com reação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, 'os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente' (TJSP, apelação 0026205.40.2008.8.26.0405).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Mantenho a prisão, recomendando-se o réu naquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF – HC n. 89824/MS – 1ª T. – unânime – Min. Carlos Ayres Britto – DJe 28/8/2008; STF – HC n. 114536/MG – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 4/12/2012; STJ – HC n. 222002/RJ – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/10/2013).

No caso o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo. A infração penal praticada é grave e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção da prisão do acusado.

O tráfico é crime de enorme gravidade, nefasto, que dissemina as drogas e deturpa a sociedade, destruindo seres humanos e lares e que ampara todo o mundo da criminalidade.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão do réu (artigo 387, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Diante de tal quadro, verificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar do réu, resulta cumprido o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixa-se de cumprir o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permanece preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes – 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Declaro o perdimento dos valores apreendidos, bem como da motocicleta em favor da União Federal.

Com relação ao dinheiro, não foi comprovado que realmente advinha de lícito labor, impondo-se o perdimento.

Registre-se que seriam fatos de prova relativamente facilitada. Prova documental, no caso concreto, seria a única hábil à comprovação das alegações e não veio para os autos.

Naquilo que tange à motocicleta, resultou comprovado que o réu dele se valeu para a traficância.

Ressalte-se que o perdimento dos bens relacionados ao tráfico de drogas é medida que se impõe ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63, da Lei 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, e sua interpretação dada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 647, em sede de repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Segue a ementa do referido julgado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5º, caput, e XXII). 2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição. 3. O confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, sob o viés de que “o crime não deve compensar”, perspectiva adotada não só pelo constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. 4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados. 5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais. Precedente: HC 104410, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 26-03-2012. 6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-2009. 7. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO E CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva ativa a agravo, suspendendo-se acórdão impugnado mediante extraordinário a que visa imprimir trânsito, quando o pronunciamento judicial revele distinção, não contemplada na Constituição Federal, consubstanciada na exigência de utilização constante e habitual de bem em tráfico de droga, para chegar-se à apreensão e confisco - artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (AC 82-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 3-2-2004, Primeira Turma, DJ de 28-5-2004). 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento." (RE 638491, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017) - original sem destaque.

Dessa forma, decreto o perdimento do veículo em questão, assim como do dinheiro, destinando-os à União Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Gustavo Cristiano Ferreira à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e à pena de 1 ano de detenção e 10 dias multa, como incurso no artigo 12, caput, da Lei nº 10.823/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. O início de cumprimento pelo tráfico se dará no regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, e, com relação à posse de munição, se dará no regime aberto, negando-lhe a possibilidade de recurso em liberdade. Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03. Condeno, ainda, ao perdimento do valor apreendido.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 3 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA